دار المنظومة
DAR ALMANDUMAH
الرواد في قواعد المعلومات العربية

العنوان:	تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقارى
المصدر:	مجلة رسالة الدفاع
الناشر:	هيئة المحامين بالناظور
المؤلف الرئيسي:	حضري، عبدالعزيز
المجلد/العدد:	ع2
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2001
الشهر:	نونير
الصفحات:	4 - 36
رقم MD:	791944
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo
مواضيع:	القوانين والتشريعات، التحفيظ العقارى، القانون المدنى، قانون العقارات، المغرب
رابط:	https://search.mandumah.com/Record/791944

© 2019 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

تطبيـق قواعـد المسطـرة المدنيـة أمام قضاء التحفيظ العقاري

ذ. عبد العزيز حضري (*)

من المبادئ العامة المسلم بها قضاءا وفقها، أن النص الخاص أولـى وأسبق في التطبيق من النص العام، وأن هذه القاعدة تشمل قواعد الموضوع، والإجراءات على حد سواء، ويترتب عن إعمالها، القـول بضرورة تطبيق النصوص المسطرية الواردة في ظهير التحفيظ (ظهير 12 غشت 1913) بالأسبقية عن نظيرتـها الـواردة فـي قـانون المسطرة المدنية، لكن الإشكال يطرح عند سكوت ظهير التحفيظ عن معالجة مسألة مسطرية معينة، وهل يجوز اللجوء بشأنها إلى النص المسطري العام؟ أم يجب التمسك باستبعاد نصوص المسطرة المدنية مطلقا إلا في الحالات التي يحيل عليها ظهير التحفيظ صراحة .

ومن المعلوم أن الفصول من 32 إلى 51 من ظهير التحفيظ حددت قواعد المسطرة الواجب اتباعها للفصل في النزاعات الناشئة عن مطلب التحفيظ، لكن، وكما أشار إلى ذلك فقه الحماية نفسه، ومنذ أزيد من نصف قرن، فإن الفصول المذكورة أعلاه لا تعالج جميع القضايا المسطرية المرتبطة بالتطور العادي للنزاع، ولذلك تم التساؤل في حينه عن إمكانية اقتباس قواعد المسطرة المدنية لسد الفراغ الملاحظ في ظهير التحفيظ، وتم القبول، بأن يترك لقواعد المسطرة المدنية مجال للتطبيق في قواعدها التي لا تتعارض مع نصوص ظهير التحفيظ العقاري[1] لكن القضاء المغربي، قبل

(*) - أستاذ باحث – كلية الحقوق – وجدة

(1) - جاك كايي : تنظيم قضائي ومسطرة مغربية 1948 – ص 327.

الاستقلال، وبعده، وسواء في ظل قانون المسطرة القديم أو الحالي لم يسلم بذلك، وظل متمسكا، إلى عهد قريب جدا، بأن قانون التحفيظ ، هو قانون الموضوع والإجراءات بالنسبة لنزاعات التحفيظ، لكن ذلك لم يمنع من صدور بعض القرارات، ومن المجلس الأعلى نفسه، تم الاعتماد فيها على قواعد المسطرة المدنية، إن صراحة، أو ضمنا، وسواء تحت ظل القانون القديم أو الحالي، الأمر الذي يصبح يثير تساؤلات عديدة لدى الممارسين والمهتمين بقضايا التحفيظ، بخصوص الحالات التي يمكن فيها اعتماد قواعد المسطرة المدنية في هذه القضايا، والحالات التي لا يجوز فيها ذلك ، لذلك ارتأينا معالجة هذا الموضوع بمنهجية تعتمد أساسا المقارنة بين نصوص قانون التحفيظ وقواعد المسطرة المدنية، لاستجلاء عناصر الاختلاف بين القانونين، منذ وضع القضاء يده على النزاع إلى إصدار الحكم وتبليغه والطعن فيه، في محاولة لتحليل وفهم قرارات المجلس الأعلى سواء تلك التي استبعدت تطبيق قانون المسطرة المدنية، أو تلك التي أقرت تطبيقها.

المبحث الأول
أوجه اتفاق واختلاف القواعد المسطرية بين قانون التحفيظ وقانون المسطرة المدنية

يلاحظ أن الاختلاف الحاصل بين نصوص ظهير التحفيظ، وقانون المسطرة المدنية، لا يقتصر على نوع وطبيعة القواعد الواجب إعمالها لعرض النزاع على القضاء، والتحقيق فيه، وإصدار الحكم وتبليغه والطعن فيه، وإنما تختلف أيضا في طريقة صياغتها التشريعية، عندما تعالج معا موضوعا واحدا مشتركا، أو مسألة معينة بذاتها، وكثيرا، ما رتب القضاء لمجرد اختلاف هذه الصياغة آثارا مهمة، وسن قواعد خاصة واجبة التطبيق أمام قضاء التحفيظ تبعا لهذا الاختلاف.

وذلك ما سيتبين من خلال استعراضنا للقواعد المنظمة لعرض نزاع التحفيظ على القضاء والتحقيق فيه من طرفه، ودور النيابة العامة في هذا النزاع، وإمكانية التدخل فيه، وإصدار الحكم وتبليغه، ثم الطعن فيه.

أولا : تحقيق نزاع التحفيظ من طرف القاضي المقرر

يضع القضاء يده على نزاعات التحفيظ بإحالة مطلب التحفيظ ووثائقه من قبل محافظ الملكية العقارية على المحكمة المختصة، حيث يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا يكلف بتحضير حل للنزاعات المثارة بسببه (الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير التحفيظ).

وطبقا للفصل 34 من ظهير التحفيظ أيضا يجب على " القاضي المقرر أن يقوم بتحضير القضية، فيتخذ لهذه الغاية جميع الإجراءات المناسبة، ويمكنه على الخصوص إما تلقائيا، أو بطلب من أحد الخصوم أن يقف على عين العقار الجاري فيه التحفيظ، ليقوم بتطبيق الرسوم عليه، أو بالاستماع إلى الشهود.

وبهذا الخصوص تحيل الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير التحفيظ على قانون المسطرة المدنية ، إذ تقضي بأنه " يراعي حينئذ القاضي المقرر القواعد المقررة في المرسوم الملكي المتعلق بالمسطرة المدنية".

وتبعا لذلك، فإن القاضي المقرر يستمع إلى الشهود في عين المكان أو في مكتبه طبقا لمقتضيات المواد من 71 إلى 84 من ق م.م كما يمكنه ، أن يقوم بسائر إجراءات التحقيق ومعاينة الأماكن طبقا لإجراءاتها المنصوص عليها في الفصول 55 وما بعدها من ق.م.م. بل ويمكنه طبقا للفصل 334 من ق.م.م الواجب التطبيق من قبل القاضي المقرر تبعا للإحالة الواردة بالمادة 34 من ظهير التحفيظ، أن يأمر بتقديم جميع المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق، سواء كانت موجودة بيد الأطراف، أو الغير،

أو إدارة عمومية [1].

وطبقا للفصلين 35 و36 من ظهير التحفيظ، فإنه " عندما يرى القاضي المقرر أن القضية أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها، وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بإضافة أجل المسافة".

ويذكرهم بأن في إمكانهم حضورها شخصيا أو بواسطة وكيل خاص و " عند افتتاح المناقشات يعرض المقرر القضية، ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي " .

وتختلف صياغة المادتين 35 و 36 من ظهير التحفيظ عن المادتين 335 و 342 من ق.م.م حيث تقضي المادتان الأخيرتان، أن القاضي المقرر يصدر عند انتهاء التحقيق أمرا بالتخلي عن الملف، ويحرر تقريرا يضمنه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، يتلى في الجلسة من طرفه بمجرد النداء على القضية، ما عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يعترض الأطراف.

ويثير هذا الاختلاف بين النصوص المسطرية ونصوص قانون التحفيظ بعض التساؤلات كالتالي :

1- هل يلزم القاضي المقرر في نزاعات التحفيظ بإعداد تقرير؟

2- وهل يلزم بإصدار أمر بالتخلي ؟

3- وهل يلزم تلاوة التقرير المعد من قبله في الجلسة؟

بخصوص السؤال الأول، فإن الفصل 35 من ظهير التحفيظ المطبق أمام المحكمة الابتدائية لا يوجد فيه ما يشير على ضرورة إعداد هذا التقرير لكن العمل القضائي جرى بإعداده، بل وبتفصيل كبير، يقسم فيه هذا التقرير إلى عدة أجزاء، وربما

---

[1] انظر قرار المجلس الأعلى عدد 2246 بتاريخ 25 شتنبر 1985 : عبد العزيز توفيق : قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ ، ص 164 وقد جاء فيه " إن مقتضيات المادة 334 من ق.م. المطبقة في قضايا التحفيظ، حسب ما أشير إليه في الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ، تمنح المقرر سلطة الأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها التحقيق في الدعوى".

استأنس القضاة المقررون بما يقوم به زملاؤهم أمام محاكم الاستئناف، التي تحكم حالتهم مقتضيات المادة 45 من ظهير التحفيظ التي جاء فيها " تبتدئ المناقشات بتقرير المستشار المكلف الذي يعرض القضية " كما أن المادة 35 من نفس القانون المطبقة أمام المحاكم الابتدائية نصت على أنه " عند ابتداء المناقشات يعرض المقرر القضية " ولا شك أن عرض القضية يقتضي بالضرورة إعداد تقرير عنها.

لكن هل يلزم تلاوة هذا التقرير في الجلسة؟ وماذا يترتب عن عدم تلاوته، وهل يجوز إعفاء المقرر منه بتدخل من الرئيس كما تقضي بذلك مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 342 من ق.م.م.؟

لقد أكد المجلس الأعلى في أحد قراراته إن تلاوة التقرير من طرف المقرر حق من حقوق الدفاع[1]، كما أكد في قرار آخر إن تلاوة التقرير إجراء مسطري لا يترتب على خرقه البطلان، إلا إذا ألحق ضررا بالطاعن[2].

وفي القرارين معا، رفض المجلس الأعلى نقض القرار الاستئنافي، لعلة أن طالب النقض لم يثر هذا الخرق أمام محكمة الموضوع، فإثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبولة، وذلك في قراره الأول، ولكون الطاعن لم يدع أن ضررا لحقه بعدم تلاوة التقرير في القرار الثاني، وفي قرار ثالث أشار إلى أن الاعتراض على الإعفاء من تلاوة التقرير يجب أن يكون بمبادرة من الطرف الذي يعنيه الأمر[3].

وفيما يتعلق بصدور الأمر بالتخلي " حيث أن القضية تتعلق بالتحفيظ العقاري، وتحكمها مقتضيات الفصل 44 من ظهير التحفيظ الذي لا يشير إطلاقا إلى هذا الإجراء.

---

(1) - قرار رقم 2477 بتاريخ 1992/10/21 عبد العزيز توفيق – قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 257.

(2) - قرار رقم 492 بتاريخ 29 يوليوز 1997 – عبد العزيز توفيق – قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 337.

(3) - القرار رقم 489 بتاريخ 20 فبراير 1991 ، عبد العزيز توفيق- م. س.ص 236 .

فإن عدم صدوره من المقرر لا يعيب الحكم، ولا يعرضه للنقض "[1]، وفي قرار آخر أكد المجلس الأعلى نفس الموقف قائلا : " إن الفصل 44 من ظهير التحفيظ لا يشترط اتخاذ الأمر بالتخلي عن القضية "[2]، وفي قرار ثالث قرر أن عدم تبليغ القرار بالتخلي قد ترك الباب مفتوحا في وجه الطاعن ليدلي بكل ما يفيده إلى أن حجزت القضية للمداولة[3].

وللإشارة ، فإن المجلس الأعلى، سبق له أن رفض نقض قرار في المادة المدنية العادية لعدم اتخاذ أمر بالتخلي ، وعلى فرض ثبوته، فإنه يترك الباب مفتوحا في وجه الطرفين إلى حين وضع القضية في المداولة، وذلك شيء لم يتضرر منه الطاعن"[4].

وإذن، فإذا كان عدم صدور الأمر بالتخلي لا يعيب الحكم في المواد العادية التي تحكمها مقتضيات المادة 335 م.م. وفيها إشارة إلى اتخاذ هذا الإجراء من قبل المقرر، فإنه من حق المجلس الأعلى ألا يعتبر عدم صدوره في مادة التحفيظ موجبا لنقض الأحكام الصادرة في إطارها، لعدم الإشارة إليه في المادة 44 من ظهير التحفيظ.

ثانيا : دور النيابة العامة

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا في نزاع التحفيظ العقاري إذ يسمح لها الفصل 26 من ظهير التحفيظ أن تتدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض باسم الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين، وبذلك تصبح طرفا في

---

(1) - القرار رقم 399 بتاريخ 13 فبراير 1991 – المرجع السابق ص 233.

(2) - القرار رقم 6194 بتاريخ 22 أكتوبر 1996 – المرجع السابق – ص 334.

(3) - القرار رقم 688 بتاريخ 10 نونبر 1982 – المرجع السابق – ص 137.

(4) - قرار رقم 1007 بتاريخ 1985/2/10 – غير منشور : أورده عبد العزيز توفيق – شرح المسطرة المدنية – الجزء - ص .

الدعوى وتكون مدعية كسائر المتعرضين، ولها حق متابعة الدعوى إلى أن يصدر بشأنها حكم نهائي .

لكن في غير هذه الحالة، هل يجب تبليغ ملفات قضايا التحفيظ إلى النيابة العامة، وهل يجب عليها أن تقدم مستنتجات كتابية في الجلسة ؟

إن الفصل 37 من ظهير التحفيظ يشير إلى أنه بعد تقديم المقرر لعرضه، والاستماع إلى الأطراف، " يقدم ممثل النيابة العامة ، إن اقتضى الحال استنتاجاته " ، وعبارة إن " اقتضى الحال " تفيد أن تقديم هذه المستنتجات ليس ملزما، ولذلك ذهب المجلس الأعلى في قرار قديم له إلى أنه " لا يقتضي الفصل 42 من ظهير التحفيظ تبليغ الملفات إلزاميا إلى النيابة العامة، كما أن الفصل 45 من نفس الظهير، لا يوجب على النيابة العامة أن تقدم في قضايا التحفيظ ملتمسات كتابية :[1]

لكن ، إذا كان أحد أطراف النزاع قاصرا، فإن الفصل 9 من ق.م.م يوجب أن تبلغ النيابة العامة بالدعوى التي يكون طرفا فيها، ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء بطلان الحكم الصادر بدون احترامه، وقد طبق المجلس الأعلى مقتضيات المادة 9 من ق.م.م في دعاوي التحفيظ العقاري ، ولو أنه لم ينقض هذه الأحكام ، إما لأن "الطاعنين لم يبينوا، من هم هؤلاء المحاجر الذين كانوا أطرافا في الدعوى، وهل من الفريق الطاعن أم من الفرقاء الآخرين، حتى يراقب المجلس ، ما إذا كانت المحكمة ملزمة بتبليغ الملف إلى النيابة العامة "[2]، أو لأن " الإجراء المنصوص عليه في المادة 9 من ق.م.م قرر لمصلحة القاصر، وأن هذه الأخيرة لم تتضرر مما قضت به المحكمة، ولا مصلحة للطاعن في إثارته لتعلقه بالغير "[3].

---

(1) - قرار مدني رقم 16 بتاريخ 13 أبريل 1961 – رشيد عبود – مجموعة القوانين الضبطية والتنظيمية – الجزء الثاني 1978.3 .

(2) - القرار رقم 399 بتاريخ 13 فبراير 1991 – عبد العزيز توفيق م.س.- ص 233.

(3) - القرار رقم 1430 . 12 مارس 1996 – نفس المرجع – ص 318.

ويلاحظ أن نفس الموقف تتبناه المجلس الأعلى في قضايا مدنية أخرى عادية[1].

ثالثا : التدخل أمام محكمة التحفيظ

طبقا لقواعد ق.م.م، فإنه يحق لكل من له مصلحة في نزاع معروض على القضاء أن يتدخل فيه (م111 م.م)، وطبقا للمادة 115، فإنه عند وفاة أحد الأطراف، أو حصول تغيير في أهليته، يستدعي القاضي من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إن لم تكن الدعوى جاهزة للحكم، أما التدخل في المرحلة الاستئنافية فقد حصره مشرع المسطرة المدنية في من لهم الحق في ممارسة تعرض الخارج عن الخصومة (م144 م م)، أما في مرحلة النقض فلا يكون التدخل إلا انضماميا لمؤازرة أحد الطرفيين (م 377 م م).

أما قانون التحفيظ العقاري ، فلم يرد فيه نص يعالج التدخل في المرحلة الابتدائية، لكنه أحال على مقتضيات الفصل 144 م م ، بالنسبة للاستئناف، وهو نفس ما فعله بالنسبة للتدخل أمام المجلس الأعلى، بمقتضى الفصل 47 من ظهير التحفيظ الذي أحال على ظهير 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس ، (المادة 34 من الظهير المذكور – المادة 377 من ق م م).

فهل يكون التدخل مقبولا في المرحلة الابتدائية في قضايا التحفيظ ، للدفاع والمؤازة، أو لتصحيح المسطرة إثر وفاة أحد الأطراف؟

---

[1] - كما في قراره عدد 324 بتاريخ 1978/7/7 – قضاء المجلس الأعلى عدد 25 – ص 63 . وقراره عدد 52 الصادر بتاريخ 1983/2/9 – قضاء المجلس الأعلى عدد 30 – ص 55.

1- التدخل للدفاع والمؤازرة

كان فقه الحماية قد ذهب إلى القول بأن التدخل مقبول في مادة التحفيظ، كما في جميع المواد الأخرى[1]، لكن الإطلاقية التي تحدث بها هذا الفقه القديم، غير مؤكدة، لأن قانون التحفيظ كما سبقت الإشارة إلى ذلك لا يشير إطلاقا إلى إمكانية التدخل في المرحلة الابتدائية، لأن أطراف نزاع التحفيظ تتحدد أمام المحافظ، فيعرف المدعي من المدعى عليه، والمحكمة ملزمة بالبث فيه على حالته، كما قرر المجلس الأعلى ذلك مرارا وفي أكثر من قرار[2].

لكن، ألا يمكن اعتبار، ما تقضي به المادة 29 من ظهير التحفيظ، من إمكانية قبول التعرض الواقع خارج أجله من قبل وكيل الملك، تدخلا في الدعوى، وهي معروضة على المحكمة الابتدائية، لاشك أنه تدخل بالمفهوم المسطري لهذا الإجراء، لأنه يقع بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على ملف النزاع بين طرفين اصلين هما المتعرض الأصلي المدعي، وطالب التحفيظ المدعى عليه، لكن، وحيث إن كل إدعاء على عقار في طور التحفيظ يجب أن يقدم على شكل تعرض، وحيث إن هذا التعرض يقدم أصلا أمام المحافظ، واستثناءا بإذن من وكيل الملك بمحكمة النزاع، فإن الإذن بقبول هذا التعرض المتأخر، يعتبر في حقيقته إذنا بالتدخل في نزاع التحفيظ المعروض على محكمته.

لكن، وحيث إن المتعرض يعتبر دائما مدعيا طبقا للاجتهاد القار والثابت للقضاء، فإن المتعرض المتدخل بإذن وكيل الملك يتخذ بدوره هذه الصفة خلافا لقواعد التدخل العادي أمام القضاء العادي.

---

(1) - انظر جاك كايي : تنظيم قضائي ومسطرة مغربية – م ص – ص 332.

(2) - انظر قرار المجلس الأعلى عدد 76 بتاريخ 9 يناير 1991 – قضاء المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – عبد العزيز توفيق – م س – ص 220 – والقرار عدد 3590 بتاريخ 4 يولوز 1995 – المرجع السابق – ص 288.

ومع ذلك فإن الفصل 29 من ظهير التحفيظ لا يحل الإشكال خاصة إذا رفض وكيل الملك منح هذا الإذن فهل يطعن في قرار وكيل الملك، ولدى أية جهة، هل يكون القضاء الإداري مختصا ؟

ألا يكون في إباحة التدخل المباشر أمام المحكمة الابتدائية حل لكل هذه المشاكل؟ – ذلك ما نراه حلا مناسبا لتصفية نزاعات التحفيظ، كما لو فرضنا مثلا أن المتعرض الأصلي على العقار في طور التحفيظ، باع هذا العقار، فيكون من حق المشتري التدخل أمام المحكمة الابتدائية، للدفاع عن حقوقه، أو كما لو تنازل المتعرض الأصلي عن تعرضه لفائدة طالب التحفيظ، بسوء نية، إضرارا بالمشتري.

بل إن طالب التحفيظ نفسه قد يثير نزاعا يتعلق بممارسته لحق الشفعة ضد المتعرض الذي باع الجزء المتعرض عليه من العقار، فهل يطلب من طالب التحفيظ أن يثير بدوره هذا النزاع في شكل تعرض أمام المحافظ؟

ثم إذا أراد المتدخل أن يطعن بالزور المدني في الوثائق المقدمة من طالب التحفيظ أو المتعرض الأصلي ، فهل، يجب عليه أيضا أن يقدم ادعاءه في شكل تعرض أمام المحافظ؟

لا أعتقد أن رأيا سليما يمكن أن يقول بذلك، بل الصواب هو أن تقدم هذه المطالب وما شابهها بتدخل أو طلب عارض أمام المحكمة مباشرة[1].

لقد قبلت محكمة الاستئناف بالرباط قبول تدخل المشتري أمامها ، عندما لاحظت أن المتعرض الأصلي قام برفع فجائي للتعرض الذي يمكن اعتباره عملا مخادعا وتدليسيا صادرا من لدنه[2] .

---

[1] - انظر مقالة ذ. المنتصر الداودي – مسطرة التحفيظ العقاري وآثارها وإشهار الحقوق العينية وتطبيقها على الرسوم العقارية – ندوة العقار – 6 و 7 نونبر 1978 – منشورات – وزارة العدل – ص143.

[2] - قرار رقم 811 بتاريخ 24 أبريل 1929- مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1928 – 1944 – تعريب المرحوم العربي المجبود – ص 138.

ورغم أن التدخل في مرحلة الاستئناف جائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 43 من ظهير التحفيظ الذي يحيل على الفصل 234 مسطرة قديمة، الفصل 144 من مسطرة 1974، لكن هذا التدخل محصور فيمن لهم حق اعتراض الخارج عن الخصومة. والمشتري ليس واحدا منهم، لأنه يعتبر خلفا خاصا للمتعرض الأصلي، ولكن محكمة الاستئناف الرباطية سمحت له بالتدخل للسبب الذي ذكرنا.

ثم إن الفصل 144 م.م، إذ يحصر المتدخلين في الاستئناف، فمن لهم حق تعرض الخارج عن الخصومة، فلأن التدخل ابتدائيا وفقا للفصل 111 مسطرة مدنية يكون دائما مقبولا بتوفر مصلحة في النزاع المعروض على القضاء، فلذلك يكون الانسجام حاصلا بين مقتضيات الفصلين 111 و 144 مسطرة مدنية.

أما في مادة التحفيظ، فإنه يصعب القول بذلك، لأن ظهير التحفيظ، لا يشير إلى التدخل في المرحلة الابتدائية، ولا يمكن في رأينا تطبيق الفصل 144 م.م أمام محكمة الاستئناف نفسها، وبالتضييق الذي جاء به، إلا إذا فسرنا سكوت ظهير التحفيظ عن إمكانية التدخل ابتدائيا، بأنه سكوت يفيد الجواز والإباحة. لا المنع والتحريم.

لكن يظهر أن القضاء المغربي لا يسير في هذا الاتجاه ، فقد ذهبت محكمة استئناف البيضاء إلى القول بأن : " مسطرة التدخل غير مقبولة في قضايا التحفيظ العقاري التي لا تخضع لمقتضيات المسطرة المدنية، ما عدا في الأحوال المنصوص عليها فيها صراحة" [1].

كما أن المجلس الأعلى قضى بأن إدخال البائع كضامن يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة العقارية التي لا تنظر إلا في المنازعات المتعلقة بالتحفيظ التي يحيلها عليها محافظ الملكية العقارية، وأن طلب إدخال البائع في الدعوى بالإضافة إلى كونه وضع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لم يكن مقبولا " [2].

---

[1] - قرار استئناف البيضاء عدد 607 بتاريخ 22 ماي 1985 – مجلة المحاكم المغربية – عدد 48 – ص 110.

[2] - قرار المجلس الأعلى عدد 229 بتاريخ 15 ماي 1968– مجلة القضاء والقانون،عدد 93 – ص60.

2- التدخل لتصحيح المسطرة

سبقت الإشارة أن نزاع التحفيظ يقوم بين طالب التحفيظ المدعى عليه، والمتعرض المدعي. وينشأ أمام محافظ الملكية العقارية الذي يحيل ملفه على محكمة التحفيظ .

لكن قد يحدث أمام المحكمة عارض يتمثل في حصول تغيير في أهلية أحد الأطراف كموت أحد الطرفين، وبالموت تنتهي أهلية الإنسان، ولا يمكنه ممارسة حق التقاضي طبقا للمادة الأولى من ق م م، ولذلك نصت المادة 115 م م على أنه يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في وضعيته بالنسبة إلى الأهلية من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك، إن لم تكن الدعوى جاهزة للحكم " فهل يكون هذا النص قابلا للتطبيق أمام محكمة التحفيظ.

كانت المحاكم – قبل تدخل المجلس الأعلى – عندما تلاحظ وفاة أحد أطراف النزاع، تقوم بإرجاع الملف إلى المحافظ للقيام بالإجراءات اللازمة لتدخل ورثة الهالك، وهو ما كان يطرح مشاكل عملية وقانونية أمام المحافظ، ويطيل أمد المسطرة القضائية، حتى في حالة تمكن المحافظ من إنجاز اللازم، بينما كانت محاكم أخرى ترفض للورثة طلبات التدخل لتصحيح المسطرة، وكثيرا ما كانت تجد تأييدا من المجلس الأعلى[1]، الذي تدخل بوضوح ليؤكد على أنه : " إذا أحيل الملف من طرف المحافظ على المحكمة، وجب عليها أن تبث في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرضين، وإذا توفي طالب التحفيظ، وجب عليها أن تستمر في الإجراءات لتصدر حكمها بصحة التعرض أو بعدم صحته، ولا يجوز لها أن تأمر بإرجاع الملف إلى المحافظ للقيام بالإجراءات اللازمة لتدخل ورثة الهالك، إذ في إمكان هؤلاء، بعد البث في التعرض،

---

[1] - كما في قراره عدد 229 بتاريخ 15 ماي 1968 – مجلة القضاء والقانون – عدد 93/ص 60 الذي جاء فيه " لا تخضع مسطرة التحفيظ لمقتضيات ق م م ما عدا المنصوص عليها صراحة، ولهذا كانت محكمة الموضوع على صواب، عندما رفضت لطالبي النقض حق متابعة الدعوى الذي لا تنص عليه المسطرة الخاصة بالتحفيظ "

تقديم طلب أمام المحافظ بتصحيح الحالة الناشئة عن وفاة طالب التحفيظ"[1] وقد سار المجلس الأعلى بعد ذلك في نفس الاتجاه وبوضوح أكبر، عندما أكد أن " الفصل 117 من ق م م المتعلق بإدخال ورثة أحد أطراف الدعوى لا يطبق أمام محكمة التحفيظ التي يتعين عليها أن تبث في القضية المحالة عليها من المحافظ [2]، وأن طالب التحفيظ لا يجبر على إدخال ورثة أحد المتعرضين بعد إحالة الملف على المحكمة، لأن أي تغيير في هوية أطراف النزاع، بعد هذه الإحالة يكون المحافظ ملزما بتنفيذه بعد توجيه الملف إليه، بعد أن يصبح الحكم نهائيا، لأن مسطرة التحفيظ مسطرة خاصة لا تخضع لأحكام الفصل 115 من ق م م[3].

وإذن يكون تطبيق المجلس الأعلى في استبعاد تطبيق مقتضيات إدخال الورثة مؤسسا على حجيتين، الأولى هي أن قانون التحفيظ هو القانون الواجب التطبيق بدلا من ق م م، وهذا القانون لا توجد فيه مقتضيات مشابهة للمواد 115 وما بعدها من ق م م، والثانية، أن بإمكان الورثة المطالبة بتصحيح الحالة الناشئة عن الوفاة أمام المحافظ عن طريق الاستدلال بالحكم النهائي.

لكن هذه الإمكانية كثيرا ما تعترضها صعوبات، ناتجة عن رفض كثير من المحافظين لهذا الطلب بحجة أن الورثة كان عليهم أن يتقدموا بهذه الصفة أثناء عملية التحفيظ، وأن الفصل 62 من ظهير التحفيظ، يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية ، وكثيرا ما يؤيد القضاء مثل هذه القرارات الصادرة عن المحافظ عند الطعن فيها [4].

---

[1] - قرار المجلس الأعلى رقم 545 بتاريخ 29 شتنبر 1976 – عبد العزيز توفيق – مجموعة قرارات – المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 116.

[2] - القرار عدد 3590 بتاريخ 4 يوليوز 1995 – عبد العزيز توفيق – قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ م.س – ص 288.

[3] - القرار عدد 4725 بتاريخ 1995/9/26 نفس المرجع – ص 298.

[4] - قرار استئنافية الناظور عدد 275 في الملف عدد 89/134 بتاريخ 1990/6/19 قرار غير منشور.

لكن المجلس الأعلى لحسن الحظ صحح الموقف وقضى أن المحكمة التي سايرت المحافظ في رفض طلب الورثة تسجيل حقوقهم على الرسم العقاري بناءا على مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ، تكون قد أساءت تطبيق القانون[1].

ومع ذلك كان يمكن تصحيح هذا الوضع بشكل أكثر عدالة، لو سمح لهؤلاء الورثة بالتدخل في الدعوى ابتدائيا، أو استئنافيا، حتى يكونوا أطرافا في الدعوى، ويؤسس الرسم العقاري في اسمهم، بدل تحميلهم مشقة وعناء، اللجوء إلى مساطر قضائية طالت سنوات، للوصول إلى نتيجة كان يمكن الوصول إليها بأقل الجهد والتكاليف.

ومن الناحية القانونية ، بل والمنطقية، فإنه يصعب تبرير القاعدة القائلة بعدم جواز تدخل ورثة طالب التحفيظ أو المتعرض أمام محكمة التحفيظ بحجة عدم وجود نص في ظهير التحفيظ يسمح بذلك، إذ كيف يعقل أن تستمر المحكمة في نظر نزاع طرفه ميت، لأن الميت لا يمكنه أن يباشر الإجراءات القضائية والمسطرية. فلا يمكنه أن يوجه استدعاءا، أو يكلف بإحضار وثائق أو حجج، أو يرد على دفاع ودفوع خصمه" ولذلك جعل المشرع من الأهلية والصفة والمصلحة شروطا أساسية للتقاضي، وهي شروط عامة تنطبق على جميع أنواع النزاعات، ولا يجوز أن تستثني منها نزاعات التحفيظ، بل هي أولى بالخضوع لها نظرا للآثار السلبية التي ترتب عن عدم تطبيقها، والتي أشرنا إليها سابقا.

ويظهر أن القضاء قد تنبه إلى ذلك، فقد قضى المجلس الأعلى مؤخرا بأن الفصل الأول من ق م م واجب التطبيق أمام قضاء التحفيظ، وقرر أنه " بمقتضى الفصل الأول من ق م م، يتعين على المحكمة أن تنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل

---

[1] - قرار المجلس الأعلى عدد 5341 بتاريخ 24 أكتوبر 1995 – ملف مدني عدد 1113 /91 قضاء المجلس الأعلى عدد 49-50- ص 30.

تحدده له، وحيث أن المحكمة ردت استئناف الورثة الذين لم يدلوا برسم الإراثة، دون أن تنذرهم بذلك، تكون قد خرقت الفصل المذكور، وعرضت قراراها للنقض"[1].

لكن هل سيذهب المجلس الأعلى إلى التراجع عن موقفه السابق بخصوص عدم إعمال الفصول 115 وما بعده من ق.م.م أمام محكمة التحفيظ،؟ ذلك ما نعتقد أنه التطور الطبيعي لأعمال الفصل الأول من ق.م.م أمام محكمة التحفيظ.

رابعا : صدور الحكم وتبليغه

لا يتضمن قانون التحفيظ العقاري نصا يشير إلى البيانات التي ينبغي أن يتوفر عليها الحكم الصادر في مادة التحفيظ شبيه بالفصل 50 من ق.م.م الذي يشير إلى مشتملات الأحكام؟ فهل تقصي الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ من بيانات الفصل 50 ق م.م بحجة انعدام نص صريح يحيل عليها في قانون التحفيظ.

يلاحظ أن المجلس الأعلى تعامل مع الموضوع بكثير من التردد والحذر، فهو تارة ينقض الأحكام التي لا تحترم مقتضيات المادة 50 م.م، من دون الإشارة إليها وتارة أخرى يقضي بعدم النقض مع عدم وجود بيان من بيانات الفصل 50.

وهكذا قضى المجلس الأعلى مبكرا، وفي ظل المسطرة القديمة بخصوص التعليل أن " كل الأحكام يجب أن تكون معللة، وأن تفي بنفسها الأغراض المطلوبة منها، وعليه فإن المحاكم المكلفة بالفصل في قضايا التحفيظ، ليست معفاة من ذلك بالرغم من سكوت ظهير 12 غشت 1913، من تبرير أحكامها، ومن الخضوع لمقتضيات

---

[1] - قرار المجلس الأعلى عدد 5299 بتاريخ 10 شتنبر 1997 – عبد العزيز توفيق – قضاء المجلس الأعلى في مادة التحفيظ – ص 345.

المسطرة المفروضة والتي تعتبر من النظام العام "[1].

لكنه بالمقابل قضى في موضوع بيانات الحكم أنه " لا يطبق قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ العقاري إلا في الحالات التي يحيل عليها قانون التحفيظ، وليس منها الفصل 345 في فقرته الرابعة التي تنص على وجوب ، إضارة الأحكام إلى أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة "[2].

وفي قرار ثالث قضى بأن " تنصيصات المحكمة تعتبر عنوان الحقيقة حتى يثبت عكسها" وأضاف جوابا على وسيلة الطاعن أن " القرار المطعون فيه ينص على أن الهيئة الحاكمة ناقشت القضية في الجلسة، وأن الحكم صدر علنيا "[3].

وفيما يتعلق بتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ، ونظرا لأن الفصل 40 من ظهير التحفيظ جاء بمقتضيات خاصة ورد فيها أنه " بمجرد صدور الحكم، وعلى ابعد حد خلال مدة ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ، وإلى جميع الأطراف في عناوينهم المختارة، وينص هذا التبليغ على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الآجال المقررة في الفصل 226 وما بعده من قانون المسطرة المدنية "، نظرا لهذه المقتضيات

---

[1] - قرار المجلس الأعلى رقم 163 بتاريخ 20 أبريل 1960 مجموعة القوانين الضبطية والتنظيمية – رشيد عبود – الجزء الثاني 1978 ويلاحظ أن المجلس الأعلى مستقر وثابت على تعيين الأحكام غير المعللة الصادرة في مادة التحفيظ سواء في إطار قانون المسطرة القديم أو الحالي.

كما قراره عدد 858 بتاريخ 27 دجنبر 1967 الذي جاء فيه " وحيث أنه يعدم الإجابة على هذا المأخذ المرتكز على أساس قانوني، فإن محكمة الاستئناف تكون قد خرقت الفصل 189 من ظهير المسطرة الذي ينص على أن كل حكم أو قرار يجب أن يتضمن الأسباب التي من شأنها تبرير الحكم " عبد العزيز توفيق : قرارات المجلس الأعلى في التحفيظ – ص 44.

[2] - قرار عدد 132 بتاريخ 1981/4/7 عبد العزيز توفيق : قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 124.

[3] - قرار رقم 489 بتاريخ 20 فبراير 1991 – المرجع السابق – ص 236.

الخاصة فقد تمسك المجلس الأعلى في أكثر من قرار بأن هذه المقتضيات هي الواجبة التطبيق بدلا من الفصل 50 من ق.م.م.

وهكذا قضى المجلس الأعلى " أن الظهير المطبق على العقارات المحفظة لا يشترط أي شكل معين للتبليغ، كما أنه لا يحيل على قواعد المسطرة المدنية في ذلك"[1]. وقضى أيضا بأن " مقتضيات الفصل 40 من ظهير التحفيظ التي تنص على كيفية تبليغ الأحكام الابتدائية وآجال استئنافها هي الواجبة التطبيق في قضايا التحفيظ، بدلا من المقتضيات الواردة في ق.م.م عملا بمبدأ تقديم النص الخاص على النص العام[2].

وحيث أن الفصل 40 من ظهير التحفيظ هو الواجب التطبيق في مسألة التبليغ ، فقد استبعد المجلس الأعلى إمكانية التبليغ بالجلسة وفقا للمقتضيات العامة الواردة بالفصل 50 من ق.م.م[3]، لكنه من جهة أخرى اعتبر التبليغ باطلا، إذا لم تتضمن وثيقة التبليغ الإشارة إلى أجل الاستئناف، وإلى من تسلم طي التبليغ، مستندا على مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، وجاء في قراره ما يلي : " وحيث أن الفصل 39 من ق.م.م ينص على أن ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء، وفي أي تاريخ، وأن المحكمة لما قضت بعدم قبول استئناف الطاعنين اعتبارا على شواهد التسليم المخالفة للقانون، تكون قد خرقت الفصل المستدل بخرقه وعرضت قرارها للنقض"[4].

وحيث أن التبليغ في مادة التحفيظ يكون بملخص الحكم فقط، وليس بنسخة كاملة منه، فقد رتب القضاء العالي على هذا التبليغ مجموعة من الآثار المتعلقة بالاستئناف ، والتي سنشير إليها لاحقا.

---

(1) - قرار عدد 339 بتاريخ 27 أكتوبر 1977 – مجلة القضاء والقانون عدد 128.

(2) - قرار رقم 630 بتاريخ 1 مارس 1989- عبد العزيز توفيق – م.س – ص 184.

(3) - قرار رقم 1100 بتاريخ 16 ماي 1990 – عبد العزيز توفيق – م.س. ص 203 .

(4) - قرار رقم 4181 بتاريخ 1996/6/25 – المرجع السابق – ص 341.

خامسا : الطعن في الحكم الصادر في مادة التحفيظ

نص ظهير 12 غشت 1913 على طريقين للطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ، وهما الاستئناف (الفصل 41) والنقض (الفصل 47) واستبعد التعرض بنص صريح (الفصل 45)، وسكت عن باقي الطعون الأخرى، كتعرض الخارج عن الخصومة، وإعادة النظر.

وقبل التساؤل عن إمكانية ممارسة الطعنين المسكوت عنهما في ظهير التحفيظ، نتعرض فيما يلي لقواعد الاستئناف والنقض كما نظمت في ظهير التحفيظ، وقانون المسطرة المدنية .

أ – الاستئنـــــاف :

طبقا للفصل 41 من ظهير التحفيظ، فإن الاستئناف " يقبل دائما في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه" ويترتب عن ذلك أن حكم المحكمة الابتدائية في نزاع التحفيظ يعتبر دائما ابتدائيا ، قابلا للاستئناف، حتى ولو قلت قيمة العقار عن مبلغ النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقا للقواعد العامة (الفصل 19 م.م) وحتى ولو وصفت المحكمة خطأ حكمها بأنه نهائي .

هكذا وقد خص ظهير التحفيظ الاستئناف – ستة فصول (من الفصل 40 إلى الفصل 45)، تضمنت قواعد خاصة، تختلف عن قواعد م.م. ، وإحالة عليها في بعض المواد[1] كما يلي من خلال استعراضنا للمواضيع الآتية :

1- الأجـل :

يحيل الفصل 40 من ظهير التحفيظ في موضوع أجل الاستئناف على الفصل 226 وما بعده، مسطرة قديمة (الفصل 134) وما بعده من قانون المسطرة الحالي وحيث

---

[1] - وهي الفصول 226-227-228-229 م قديمة وتقابلها الفصول 134-135-136-137 من قانون المسطرة الحالي .

أن الفصل 134 يحدد أجل الاستئناف في ثلاثين يوما ، فيكون إذن هو أجل استئناف الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ.

لكن هل يقبل هذا الأجل الامتداد والانقطاع، للأسباب المذكورة في الفصول 135 إلى 137 من ق م م ؟

الملاحظ أولا أن الفصل 40 من ظهير التحفيظ لا يحيل على الفصل 226 من قانون المسطرة القديمة وحده، وإنما أيضا على ما بعده من فصول أخرى متعلقة بالأجل، وهي الفصول 227-228-229، وتقابلها الفصول 135-136-137 من قانون المسطرة الحالي.

فالفصل 228 مسطرة قديمة ، 136 من المسطرة الحالية : يقضي بمضاعفة أجل الاستئناف ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمغرب. وقد كان من الممكن القول بإمكانية تطبيق هذا الفصل المحال عليه، لولا أن الفصل 26 من القرار الوزيري الصادر في 3 يونيو 1915 يقضي بأن يكون لأطراف الدعوى لزوما موطن مختار يقع في دائرة محكمة موقع العقار المتعرض عليه، وهو الموطن الذي يبلغ فيه الحكم الابتدائي الفصل 40 ، وكذا يوم عرض القضية بالجلسة (الفصل 44).

ومع ذلك فإن الفصلين المذكورين أي 40 و44 من ظهير التحفيظ يقرران ، إمكانية " إضافة أجل المسافة" إلى الأجل الذي يمنحه المستشار المقرر للمستأنف للإدلاء بوسائل استئنافه، وكذا إلى الأجل الذي يجب أن يترك للمتقاضي لحضور الجلسة التي ستعرض فيها القضية ، ولا يوجد في ظهير التحفيظ نص آخر يحدده فهل يرجع بشأنه إلى قانون المسطرة المدنية ؟

أما بخصوص توقف أجل الاستئناف بسبب موت المبلغ إليه داخل الأجل، فإن الفصلين 137 و 139 من ق م.م يكونان واجبي التطبيق، باعتبارهما من النصوص المتعلقة بالأجل التي تشملهما الإحالة الواردة بالفصل 40 من قانون التحفيظ، التي أحالت على الفصل 226 وما بعده من ق م م الحالي .

وأخيرا يكون أيضا قابلا للتطبيق أمام قضاء التحفيظ الفصل 135 من ق م م المتعلق بالاستئناف التبعي، لأنه أيضا من النصوص المشمولة بالإحالة الواردة بالفصل 40 من ظهير التحفيظ باعتباره استئنافا يقدم خارج الأجل.

2- المقال الاستئنافي وشكلياته

ينص الفصل 41 من ظهير التحفيظ على أن طلب الاستئناف يقدم بدون مصاريف على الكيفية المذكورة في الفصل 231 من قانون المسطرة القديمة، وهذا النص الأخير يتعلق فقط بتعيين الجهة التي يقدم لها الاستئناف، ولا يشير إلى شكليات مقال الاستئناف، ويكتفي بترك الخيار للمستأنف بتقديم استئنافه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الجهة التي تبت فيه، وحيث أن الفصل 231 م م قديمة حل محله الفصل 141 من ق م الحالي، فإن الاستئناف أصبح يقدم وجوبا أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف.

أما شكليات الاستئناف في القانون القديم فقد كانت واردة بالفصل 232 الذي كان يحيل على الفصول من 145 إلى 149 م قديمة، وهذه الفصول يقابلها في قانون المسطرة الحالي الفصل 142، الذي لا تشمله الإحالة الواردة بالفصل 41 من ظهير التحفيظ.

وتأسيسيا على ذلك يكون المستأنف معفى من شكليات الفصل 142 مسطرة مدنية المتعلقة ببيان هوية وصفة ومهنة المستأنف والمستأنف ضده، ومحل إقامتهما، وكذا بيان وسائل الاستئناف والمستندات المراد استعمالها " وقد طبق المجلس الأعلى هذه القاعدة في أكثر من قرار ، مبينا أن مقال الاستئناف في مادة التحفيظ ليست له شكليات محددة، ومعفى من بيانات الفصل 142 م م، لأن الفصل 231 م قديمة يقابله الفصل 141 مسطرة حالية وحده. وهذا الأخير لم يغير شيئا من الفصل 231 م قديمة باستثناء تحديده لجهة واحدة يقدم الاستئناف أمامها[1].

---

[1] - نذكر من هذه القرارات ما يلي : 1 قرار عدد 1384 بتاريخ 14 شتنبر 1983 – عبد العزيز توفيق – قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص140. 2- قرار عدد 827 بتاريخ 13 أبريل 1985 – نفس المرجع – ص 153. - قرار عدد 76 بتاريخ 9 يناير 1991 – نفس المرجع – ص 220. 4- قرار عدد 4924 بتاريخ 29 يونيو 1997 – نفس المرجع – ص 337 .

ويرجع سبب إعفاء المستأنف من هذه البيانات إلى أن الحكم الابتدائي لا يبلغ كاملا للمحكوم عليه، وإنما يتم التبليغ بملخص عنه، كما أن نسخة الحكم ترفق وجوبا من المحكمة الابتدائية مع الملف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وهي تتضمن سائر البيانات الضرورية .

وقد رتب المجلس الأعلى عن إعفاء المستأنف من بيانات الفصل 142 م م مجموعة من القواعد الإجرائية تنظم خاصة علاقة المستأنف بالمستشار المقرر المكلف بتحضير الملف نوجزها اختصارا كما يلي :

1- لا يكون المستأنف ملزما بإيداع أوجه استئنافه إلا إذا وجه إليه . إشعار بذلك من قبل المستشار المقرر. وتبعا لذلك يكون قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الاستئناف دون أن تبحث فيما إذا كان المقرر قد وجه إلى المستأنف إنذارا قد أساء تطبيق القانون [1].

2- لا يترتب أي جزاء قانوني على عدم قيام المستأنف بما طلب منه ونتيجة لذلك، فإن المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدلاء المستأنف ببيان أوجه استئنافه رغم إنذاره من المستشار المقرر تكون قد أساءت تطبيق الفصل 42 من ظهير التحفيظ، لأنها في مادة التحفيظ تكون ملزمة بالنظر في القضية بناءا على الأوراق والوثائق الموجودة بالملف[2].

3- المستشار المقرر ليس ملزما بأن يبلغ مقال الاستئناف للمستأنف عليه، ولا أن يبلغ المستأنف جواب المستأنف عليه ولا ادعاءه، لأن الفصل 42 من ظهير التحفيظ، إنما يلزمه باستدعاء الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف[3].

---

[1] - القرار عدد 1384 بتاريخ 14 شتنبر 1983 – عبد العزيز توفيق : قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 140 – والقرار عدد 980 بتاريخ 16 مارس 1994 – نفس المرجع ص 265.

[2] - القرار عدد 168 بتاريخ 15 غشت 1985 – نفس المرجع السابق – ص 162.

[3] - قرار عدد 169 بتاريخ 20 أبريل 1960 – رشيد عبود – مجموعة القوانين الضبطية والتنظيمية – الجزء الثاني – مجموعة القانون العقاري سنة 1978 – ص 185.

ب – الطعن بالنقض :

أصبحت الأحكام الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ قابلة للطعن بالنقض ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 1957 بمقتضى التعديل الذي لحق الفصل 47 من ظهير التحفيظ بظهير 26 ماي 1958 الذي أوضح أن الأحكام الصادرة في موضوع التحفيظ تقبل الطعن فيها بالنقض وفقا لقواعده الواردة في ظهير 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى[1] وحيث إن جل هذه القواعد قد اصبح مضمنا بقانون المسطرة المدنية، وخاصة في قسمها السابع المتعلق بالمجلس الأعلى (الفصول من 353 إلى 385) فإن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق بخصوص طلبات النقض الموجهة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ.

ومع ذلك، فإن أجل الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ، هو شهران، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 47 من ظهير التحفيظ ، خلافا لما يقضي به الفصل 358 من ق م م [2].

للإشارة أيضا، فإن تبليغ الحكم الاستئنافي يتم بنسخة الحكم الكاملة للأطراف، خلافا لتبليغ الحكم الابتدائي الذي يتم بملخصه، كما أن هذا التبليغ يقع إلى جميع الأطراف في عناوينهم الحقيقية أو المختارة، خلافا لتبليغ الحكم الابتدائي الذي يقع في الموطن المختار.

---

[1] - وقد كاتب الصيغة الأصلية للفصل 47 تقضي بأن أحكام محاكم الاستئناف نهائية، ولا تقبل أي طعن. إلا من طرف النيابة العامة، ولمصلحة القانون فقط.

[2] - وانظر قرار المجلس الأعلى رقم 112 بتاريخ 6 أبريل 1982 الذي جاء فيه " لما كان الفصل 358 من ق م م ينص على أن أجل الطعن بالنقض هو ثلاثون يوما، ما لم توجد مقتضيات أخرى، فإن الفصل 47 من ظهير التحفيظ ، يعد من تلك المقتضيات الخاصة التي نص عليها الفصل 358، وحيث أن الفصل 47 من ظهير التحفيظ يحدد أجل الطعن بالنقض في شهرين من تاريخ التبليغ، فهو الواجب التطبيق – عبد العزيز توفيق : قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 130.

ويكون للطعن بالنقض أثر واقف للتنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 361 من ق م م في دعاوي التحفيظ العقاري[1].

ج – إعادة النظر

يعتبر الطعن بإعادة النظر من الطعون الاستثنائية التي انفرد قانون المسطرة المدنية بتنظيمها، وهو طعن يوجه ضد الأحكام الانتهائية، بناءا على أسباب محددة ومحصورة في القانون.

وتختلف هذه الأسباب باختلاف المحاكم التي يوجه إليها، لدرجة يمكن معها القول أن إعادة النظر نوعان، نوع يوجه ضد أحكام محاكم الموضوع، ويخضع للمواد من 402 إلى 410، وطعن يوجه ضد أحكام المجلس الأعلى ويخضع لمقتضيات المادة 397 من ق م م، والمواد الأخرى التي تحيل عليها.

أما ظهير التحفيظ، فلا ينظم هذا الطرق من طرق الطعن كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الأمر الذي أثار إشكالا قانونيا حول جواز اعتماد مقتضيات المسطرة المدنية لممارسته ضد الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ.

تجب الإشارة أولا، إلى أن إمكانية ممارسة الطعن بإعادة النظر أمام المحاكم الابتدائية غير ممكن إطلاقا، لأن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم في مادة التحفيظ العقاري تعتبر دائما ابتدائية، قابلة للاستئناف، ولذلك يستحيل الطعن فيها بهذا الطريق.

ولا تبقى إذن سوى الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف باعتبارها محاكم موضوع، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى.

---

[1] - وقد فسر المجلس الأعلى المقصود بدعوى التحفيظ العقاري بأنها " مجموع الإجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ، والتي تنتهي بإنشاء رسم عقاري" ولذلك فإن جميع الأحكام القضائية الواردة على عقار محفظ، تنفذ وفقا للمبدأ العام، وهو حيازتها على قوة الأمر المقضي، ولا يوقف النقض تنفيذها . قرار المجلس الأعلى عدد 125 بتاريخ 2 يونيو 1988 – عبد العزيز توفيق – م.س- ص178.

فبالنسبة للأولى، اعتبرت محكمة استئناف الرباط، ومنذ بداية تطبيق قانون التحفيظ ، أن المشرع باستبعاده لطرق الطعن العادية باستثناء الاستئناف، يكون قد استبعد بالضرورة أيضا الطعون الاستثنائية وتبعا لذلك فقد ردت هذه المحكمة، وفي أكثر من مناسبة طلبات قدمت لها إعادة النظر في قراراتها[1] وقد كان موقف محكمة الاستئناف بالرباط قبل الاستقلال مبررا نظرا لأن الفصل 47 من ظهير التحفيظ، وقبل تعديله بظهير 26 ماي 1958 كان واضحا في أن قرارات محكمة الاستئناف نهائية لا تقبل الطعن إلا من طرف النيابة العامة ولمصلحة القانون فقط.

أما بعد تعديل هذا الفصل بظهير 26 ماي 1958، وهو الظهير الذي نص على أن الأحكام الصادرة في موضوع التحفيظ تقبل الطعن فيها عن طريق النقض المنصوص عليه بظهير 27 شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى فإن طلب إعادة النظر أصبح موضع تساؤل، لأن ظهير 27 شتنبر 1957 المشار إليه أعلاه، نص في الفصل 36 منه على إمكانية الطعن في أحكام المجلس الأعلى في بعض الحالات، وهي حالات إعادة النظر التي أعاد الفصل 379 من ق م م . تنظيمها بوضوح أكثر.

كما أن القرارات الاستئنافية أصبحت قابلة بدورها لإعادة النظر وفقا لما قررته المادة 402 وما بعدها من قانون المسطرة الحالي.

فهل يكون طعن إعادة النظر مقبولا في قضايا التحفيظ العقاري ؟

لقد ميز المجلس الأعلى، بين إعادة النظر في القرارات الاستئنافية، وبين القرارات الصادرة عنه، وقرر بعد تردد قابلية هذه الأخيرة لهذا الطعن، لكنه منعه

---

[1] - استئناف الرباط 25 يوليوز 1922 – كازيط محاكم المغرب – 5 أكتوبر 1922 – ص 33 واستئناف الرباط 21 فبراير 1931 – مجموعة قرارات استئنافية الرباط 1931 – ص 294 – وانظر ، جاك كاي – تنظيم قضائي ومسطرة مغربية – م.س – ص 335.

بالنسبة للقرارات الاستئنافية[1].

ويبدو لنا أن هذا الموقف غير مبرر، لا من الناحية القانونية ولا من حيث ما يقتضيه المنطق السليم، ومقتضيات العدالة نفسها.

فمن الناحية القانونية يلاحظ أولا أن الفصل الثالث من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية (ظهير 28 شتنبر 1974) نص بوضوح وصراحة على أنه : "تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة ، إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها " ، ولم يرد في ظهير التحفيظ نص صريح يمنع طعن إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محكمة التحفيظ أما من حيث إعمال المنطق القانوني فإن مقتضيات الفصل 375 من ق م م التي اعتمدها المجلس الأعلى في أكثر من مناسبة لقبول إعادة النظر في قراراته، هي نفس

---

[1] - وقد حدث ذلك في نفس السنة 1989، حيث أصدر بتاريخ 14 فبراير 1989 القرار عدد 277 في الملف المدني 83/3250- وبغرفتين مجتمعتين : (الغرفة الأولى : القسم الثالث ، وغرفة الأحوال الشخصية (القسم الثاني). قرر فيه أن طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى يقبل في جميع القرارات التي يصدرها، سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو بغيرها، ولا يعتبر فيه إلا توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 379 من ق م م (القرار منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى – المادة المدنية – الجزء الثاني 1983-1991- ص 597. ثم أصدر في 5 أبريل من نفس السنة القرار عدد 887 (الغرفة المدنية : القسم الأول) ، قرر فيه أنه لا يجوز القبول بإعادة النظر في أحكام محكمة التعرض على التحفيظ استنادا إلى أحكام ق م م ، لأنه ما دام ظهير 12 غشت قد نظم الطعن، فلا يجوز الرجوع إلى قانون الشكل العام بشأن هذا الموضوع الذي تناوله لقول بطعن لا يعرفه ولم يحيل عليه في قانون المسطرة المدنية كما فعل بالنسبة لأكثر من إجراء ". القرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 43/42 نوفمبر 1989 ص 45. وللإشارة فإن المجلس الأعلى عاد ليؤكد مرة أخرى، وبغرفتين مجتمعتين، " أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى ، إذا صدر القرار دون مراعاة
مقتضيات المادة 375 من ق م م. – القرار الصادر بتاريخ 1994/10/4 في الملف عدد 98/9362. منشور بقضاء المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – عبيد العزيز توفيق – ص 273.

مقتضيات الفصل 345 من ق م م المتعلقة بقرارات محكمة الاستئناف، وكلا الفصلين يلزمان المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بضرورة تعليل القرارات الصادرة عن هذه الهيئات القضائية، الأمر الذي يقتضي إعمال نفس المبدأ: وترتيب نفس الأثر في حالة خرقه ومخالفته.

لكن المجلس الأعلى فسر الفصلين المذكورين أعلاه تفسيرا مختلفا (أي الفصلين 375 و 345)، فهو فسر الفصل 375 من ق م م تفسيرا ضيقا، حيث قرر أن "قرار المجلس الأعلى الذي يعاد النظر فيه هو القرار الخالي من كل تعليل " وأن ما قصده المشرع في هذا الفصل هو الحالة السلبية أي غياب كل تعليل بالمرة بعدم الجواب عن وسيلة أو فرع منها "[1]، أما قرارات محكمة الاستئناف، فإن عدم سلامة تعليلها أو نقصانه فقط، يعد بمثابة انعدام للتعليل ، ويعرض قرارها للنقض.

وكما لاحظ ذلك أحد كبار قضاتنا [2] فإن هذا التمييز فيه غرابة، لأنه يمنح قدسية لاجتهاد المجلس الأعلى، ويمنعه عن محكمة الاستئناف، مع أن الفارق العلمي بينهما ضئيل، ولذلك وجب على القضاء إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة، بفتح المجال أمام المتقاضين للطعن في الأحكام، سواء صدرت عن أعلى هيئة قضائية، أو عن محاكم الاستئناف.

لذلك نرى أن قرارات المحاكم الاستئنافية الصادرة في مادة التحفيظ قابلة لطعن إعادة النظر.

---

[1] - كما في قراره الصادر بتاريخ 1994/11/24 ملف إداري 93/10665 – مجلة الإشعاع – عدد 12 – يونيو 1995 – ص 173، وكذا قراره الصادر بغرفتين بتاريخ 1994/10/4 السابق الإشارة إليه.

[2] - انظر تعليق الأستاذ محمد بوزيان على قرار المجلس الأعلى رقم 277 الصادر بتاريخ 14 فبراير 1989. في نفس مرجع القرار السابق الإشارة غليه ، ص 597.

المبحث الثاني
تقدير موقف المجلس الأعلى من مسألة تطبيق قواعد المسطرة المدنية في نزاعات التحفيظ

لاشك أن تقدير موقف ما يقتضي التسليم بوجوده أولا، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، فهل يمكن الحديث عن وجود موقف واضح للمجلس الأعلى من مشكل تطبيق قواعد المسطرة المدنية في نزاعات التحفيظ؟ هل استطاع المجلس أن يقدم للمهتمين والمنشغلين بقضايا التحفيظ تصورا واضحا ومحددا للمسألة يجعلهم مطمئنين من نتيجة الطعون الموجهة إليه؟

ما الذي يمنع من أن يكون للمجلس مثل هذا الموقف والتصور الواضح، هل هي خصوصية نزاعات التحفيظ؟ أم عدم ملاءمة قواعد المسطرة المدنية؟ أم يعود السبب لظروف المجلس الخاصة ، أم كل هذا مختلطا ؟

إن المتتبع لقرارات المجلس الأعلى في الموضوع يستطيع أن يلاحظ بدون شك وقوع تطور ملحوظ في اجتهادات المجلس، انتقل من التأكيد على أن مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ما عدا المنصوص عليها صراحة ، إلى تطبيق هذه القواعد صراحة أو ضمنا في حالات خاصة، وهي ملاحظة لابد من تسجيلها لصالحه! لكن يبقى الغموض قائما على مستوى الموقف، أي على مستوى تقديم الأساس القانوني المقنع والحاسم لتحديد حالات جواز اعتماد قواعد المسطرة المدنية في نزاعات التحفيظ وكذا، نفس الأساس في حالة القول بعدم اعتمادها.

أولا : غموض موقف المجلس الأعلى

إنما نقصد بهذا الغموض، أن المجلس الأعلى لم يستطع أن يبلور مبدأ عاما، أو معيارا حاسما يرفع اللبس عن موقع قانون المسطرة المدنية بالنسبة لنزاعات التحفيظ، فهو عندما يستبعد تطبيق قواعدها، يستند إلى نفس الجواب المكرر وهو أن قانون

التحفيظ هو قانون الموضوع والشكل، وعندما، ينقض قرارا استئنافيا، لعدم احترام مقتضيات المسطرة المدنية يكتفي بالتصريح أن بعض هذه المقتضيات واجبة التطبيق في نزاعات التحفيظ بالرغم من سكوت ظهير 12 غشت 1913 وأحيانا يكتفي بالإشارة إليها، كأساس قانوني لنقض هذه القرارات.

إن استقراء بعض قرارات المجلس يفيد فعلا، أن اعتماد المجلس على قانون المسطرة المدنية لنقض بعض الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ كثيرا ما يقع في حالات يكون فيها خرق القانون المسطري واضحا وجليا، كحالة عدم تعليل محكمة الاستئناف لقرارها[1]. أو خرق حقوق الدفاع[2] أو مبدأ التقاضي على درجتين[3]، أو تبليغ النيابة العامة بقضايا القاصرين[4]- أو سلامة التبليغ[5] أو شروط التقاضي[6].

ولا شك أن هذه القواعد تعتبر قواعد جوهرية في قانون المسطرة، ولكن ألا يدل الاعتماد عليها وحدها دون غيرها، عن سلوك قديم وتقليدي في التمييز بين قواعد المسطرة المدنية الجوهرية وغير الجوهرية ، ألم يقض قانون المسطرة الحالي على هذا

---

[1] - قرار المجلس الأعلى رقم 163 أبريل 1960 – مجموعة القوانين الضبطية والتنظيمية : رشيد عبود – الجزء الثاني – طبعة 1978 – ص ، وقد جاء فيه " كل الأحكام يجب أن تكون معللة، وأن تعني بنفسها الأغراض المطلوبة منها، وعليه فإن المحاكم المكلفة بالفصل في قضايا التحفيظ العقاري ليست معفاة من ذلك، بالرغم من سكوت ظهير 12 غشت 1913 من تبرير أحكامها، ومن الخضوع لمقتضيات المسطرة المفروضة والتي تعتبر من النظام العام ".

[2] - قرار المجلس الأعلى عدد 2246 بتاريخ 25 شتنبر 1985 – عبد العزيز توفيق – قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 164. وكذلك قرار المجلس الأعلى رقم 489 بتاريخ 23 يوليوز 1996 – نفس المرجع – ص 331.

[3] - قرار المجلس الأعلى رقم 364 بتاريخ 13 فبراير 1985 – عبد العزيز توفيق قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة – ص 149.

[4] - قرار المجلس الأعلى عدد 339 بتاريخ 13 فبراير 1991 – نفس المرجع –ص 233 ، وكذلك القرار عدد 1430 بتاريخ 12 مارس 1996 – نفس المرجع – ص 318.

[5] - قرار المجلس الأعلى عدد 4181 – بتاريخ 25 يونيو 1996 – نفس المرجع – ص 341.

[6] - قرار المجلس الأعلى – عدد 5299 بتاريخ 10 شتنبر 1997 نفس المرجع – ص 345

التمييز، الذي يبدو أن بعض مستشاري المجلس الأعلى لا زالوا متأثرين به، كما كان واردا في قانون المسطرة القديم ؟

فهل توجد في قانون المسطرة المدنية قواعد جوهرية للمرافقات ، يحق نقض وتكسير الأحكام القضائية التي تخالفها أيا كان مصدرها، قضاءا مدنيا أو عقاريا أو حتى جنائيا، وأخرى غير جوهرية ، يجب التعامل معها حسب ظروف الحال ، وطبيعة القضاء مصدر القرار ؟ أجل، توجد في قانون المسطرة المدنية قواعد جوهرية للمرافعات لكن، القانون لا يجعل منها وحدها سببا للنقض، بل إن خرق أية قاعدة مسطرية كيفما كانت طبيعتها. يعتبر سببا كافيا لنقض الحكم أو القرار الذي خرقها، بشرط أن يلحق هذا الخرق ضررا بأحد الأطراف، فالعبرة إذن لم تعد لطبيعة القاعدة المسطرية جوهرية أو غير جوهرية، وإنما العبرة للضرر الذي يلحقه عدم احترامها بأحد أطراف النزاع.

ومن جهة أخرى، فإن قانون المسطرة المدنية، يتضمن أيضا قواعد هي بمثابة مبادئ عامة للتقاضي، وأمام أية جهة قضائية، وبشأن أي نزاع، كالمادة الأولى الخاصة بشروط التقاضي، والرابعة التي تمنع القاضي من النظر في النزاع مرتين، والخامسة التي توجب على المتقاضي ممارسة حقوقه بحسن نية، ولهذا اعتبرت المسطرة المدنية شريعة عامة للمرافعات. فهل تستبعد هذه المبادئ العامة من التطبيق، لأن المساطر الخاصة لبعض أنواع النزاعات، لا تنص عليها؟ ومنها مسطرة التحفيظ.

ثانيا : محاولة إيجاد الأساس القانوني لاستبعاد تطبيق المسطرة المدنية في نزاعات التحفيظ .

حاول المجلس الأعلى في أحد قراراته، أن يقدم أساسا قانونيا، وتبريرا لاستبعاد تطبيق قواعد المسطرة المدنية في نزاعات التحفيظ ، فجاء تبريره غير مقنع، بل ومتعسفا فكان سكوته السابق، أفضل من نطقه.

وكانت مناسبة صدور هذا القرار طعن بالنقض ضد قرار استئنافي رفض طلب إعادة النظر فيه، وهو الرفض الذي أيده المجلس الأعلى مؤسسا هذا الرفض على الأسس التالية :

1- أن ظهير 12 غشت هو قانون موضوع وقانون شكل كذلك .

2- أن سكوت ظهير التحفيظ عن طعن إعادة النظر يفيد استبعاده.

3- وأن استبعاد ظهير التحفيظ لطعن التعرض صراحة هو مجرد تأكيد لهذا الاستبعاد، وكان يكفي السكوت عنه لاستبعاده هو أيضا .

4- وأن قانون التحفيظ قانون خاص، لكنه ينظم موضوع الطعن في الأحكام بكامله[1].

---

[1] - ونود فيما يلي أهم حيثيات هذا القرار : " حيث أن ظهير 12 غشت 1913 هو قانون الموضوع، وقانون الشكل كذلك، فقد تضمن الإجراءات التي تتخذها محكمة التعرض على التحفيظ، وكذا الأحكام التي تصدرها، وكيفية تبليغها، وطرق الطعن التي ترد على هذه الأحكام، فنص على أن هذه الأحكام يطعن فيها دائما بالاستئناف كطعن عادي وحيد دون التعرض، ومهما كانت قيمة العقار، كما نص على أنها يطعن فيها بالنقض كطعن استثنائي، وسكت عن الطعن بإعادة النظر، وأن سكوته عن هذا الطعن الاستثنائي يحمل على أن المشرع أراد استبعاده، بحيث لا يجوز القبول بإعادة النظر في أحكام محكمة التعرض على التحفيظ استنادا إلى أحكام قانون المسطرة المدنية، لأنه ما دام ظهير 12 غشت قد نظم طرق الطعن، فلا يجوز الرجوع إلى قانون الشكل العام بشأن هذا الموضوع الذي تناوله للقول بطعن لا يعرفه، ولم يحل عليه في قانون المسطرة المدنية كما فعل بالنسبة لأكثر من إجراء، ولا وجه للقول بهذا الطعن لمجرد أن المشرع لم يستبعده صراحة، كما فعل بالنسبة للتعرض، لأن التعرض كان يكفي استبعاده هو الآخر لمجرد السكوت عنه، وأن التنصيص على هذا الاستبعاد كان مجرد تأكيد له، ولا وجه للاستدلال بما جاء في الفصل الثالث من الظهير بمثابة قانون بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، لأن ما ورد في هذا الفصل يهم القوانين الخاصة التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله، وظهير التحفيظ قد نظم كما سبق القول الطعن في الأحكام بمقتضيات خاصة، وبهذا تكون المحكمة على صواب حين صرحت بعدم قبول إعادة النظر " قرار المجلس الأعلى عدد 887 بتاريخ 5 أبريل 1989 – مجلة قضاء المجلس الأعلى – عدد 42 – ص 45.

ولا شك أن قراءة حيثيات هذا القرار تبرز بوضوح أن هم المجلس الأعلى كان هو الرد عن وسائل النقض المفحمة التي تمسك بها الطاعن وهي ترتكز على فرعين أساسيين:

1- إذا كان سكوت مشرع ظهير 12 غشت 1913 عن طعن إعادة النظر يفيد استبعاده له، فلماذا لم يسكت أيضا عن طعن التعرض ، الذي خصه بالمنع الصريح؟

2- إذا كان ظهير 12 غشت قانونا خاصا ، فإن الفصل الثالث من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية، ينص صراحة على أن " تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها " ، وذلك بعد أن أكد نفس الفصل على أن محاكم الاستئناف والمحاكم تستمر في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون .

وقد أجاب المجلس الأعلى عن الوسيلة الأولى بأن المشرع كان يكفيه السكوت عن طعن التعرض لاستبعاده، وأن تنصيصه عليه هو لمجرد التأكيد، ويفهم من هذا الجواب، أن الجزء الأول من مقتضيات الفصل 45 من ظهير التحفيظ [1] هي مجرد إطناب تشريعي ، وزيادة من المشرع، والحال أن القواعد الأولية للتفسير والاجتهاد تقول أن إعمال الكلام خير من إهماله، وأن المشرع منزه عن العبث، باعتباره عاقلا.

بينما أجاب عن الوسيلة الثانية، بأن الفصل الثالث من قانون المسطرة الذي يوجب تطبيق قانون المسطرة المدنية حتى في القضايا التي تنظمها نصوص خاصة، إذا

---

[1] - وينص هذا الجزء على أنه : " تبث محكمة الاستئناف سواء حضر الأطراف أو تخلفوا ، دون أن يقبل أي تعرض ضد الحكم الصادر".

لم يرد فيها نص صريح خاص بها بأنه لا ينطبق إلا على القوانين الخاصة التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله، وظهير التحفيظ نظم الطعن في الأحكام بمقتضيات خاصة.

وهذا الرد لا يخلو من تعسف واضح، فهو حاول أن يحدد مجال تطبيق الفصل الثالث من ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية بأنه يقتصر على القوانين الخاصة التي لا تنظم موضوعا معينا بكامله، والحال أن هذا الفصل الثالث لا يفرق في القوانين الخاصة بين ما ينظم موضوعا معينا بكامله، وبين من ينظمه جزئيا، بل يمكن القول أن هذه التفرقة تتنافى كليا مع نص الفقرة الثانية من هذا الفصل الثالث، التي نصت بوضوح على أن قانون المسطرة المدنية واجب التطبيق في المساطر الخاصة، التي لم يرد فيها نص صريح خاص بها، ولم يرد في ظهير التحفيظ نص صريح أو غير صريح، يجيز أو يمنع طعن إعادة النظر في القرارات الاستئنافية، ولا يمكن اعتبار سكوت المشرع في النصوص المسطرية الخاصة عن تنظيم موضوع أو مسألة معينة، سوى بالإباحة ، لأنها الأصل، وهي تتنافى مع التخصيص المقصود من وضع النص الخاص، لأن الأصل في التخصيص هو منع المباح العام لأسباب خاصة ارتآها المشرع، أو إباحة الممنوع العام، في حالات خاصة، أو تقييد المباح العام، أو الممنوع العام، لأسباب وظروف خاصة اقتضتها إرادة المشرع.

وحيث أن طعن إعادة النظر، هو من الطعون المسموح بها بالنص العام، فإن سكوت النص الخاص عن منعه، أو تقييده، يفيد إبقاء العام على أصله، وهو ما يقتضي تطبيق قواعد المسطرة المدنية بشأنه باعتبارها نصا عاما أولا، وذلك، حتى في حالة سكوت ظهير المصادقة على قانون المسطرة المدنية عن حالة النصوص الخاصة، أما، مع وجود هذا النص الواضح والصريح، فإن كل " اجتهاد" لتعطيله، ووقف تنفيذه ، يعتبر اجتهادا مخالفا للنص، بل ولا يسمى " اجتهادا " في عرف الأصوليين.

ولذلك فإن ما ينطبق على طعن إعادة النظر كمسألة مسطرية، ينطبق على غيره، من سائر القضايا المسطرية الأخرى، التي لم يرد بشأنها نص خاص في ظهير التحفيظ.

وأخيرا، فإننا نرى، أن قانون المسطرة المدنية يمكن أن قدم حلولا إيجابية، لما تعانيه نزاعات التحفيظ، من مشاكل ، إذا اعتمد كنص مرجعي عام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في ظهير التحفيظ.